

[汚職の罪]に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 公務員が賄賂を受け取って、他の公務員の職務について働き掛けを行った場合、違法な行為の働き掛けがあったときにのみみせけん収賄罪が成立し、他の公務員の裁量判断に不当な影響を及ぼす程度では同罪は成立しない。
2. 収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは、問うところではない。
3. 公務員が自己に代わって債務を弁済してもらったことが賄賂になる場合のように、賄賂として収受した無形の利益についてはおよそ没収の対象とはならないが、金銭に換算可能であれば、その価額は追徴しなければならない。
4. 公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、借金という形をとっても実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば、当該金銭は没収の対象となるが、本当に借金をしたにすぎない場合には、刑法第197条の5の規定によっては、受領した金銭を没収することはできない。
5. 公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受したものの、実際には秘密を漏らさなかった場合には、受託収賄罪が成立するが、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立する。

No422	収賄罪	正答率
H19-9	正解 1	62%

1 誤っている

最決平15.1.14(百選Ⅱ110事件)は、公務員が、請託を受けて、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いをもって調査中の審査事件について、同委員会の委員長に対し、これを告発しないように働きかけることは、同委員会の裁量判断に不当な影響を及ぼし、適正に行使されるべき同委員会の告発及び調査に関する権限の行使をゆがめようとするものであるから、平成7年法律第91号による改正前の197条の4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あつせんすることにあたる」と解すべきであるとしている。

2 正しい

本記述は、収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは問うところではないとする。この点、最大判平7.2.22(百選Ⅱ107事件)は、「賄賂罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とするものであるから、賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは、問うところではない。ただし、公務員が右のような行為の対価として金品を受受することは、それ自体、職務の公正に対する社会一般の信頼を害するからである。」と述べている。

3 正しい

本記述前段は、没収の対象を問うものである。この点、没収の対象たる「收受した賄賂」とは、「物」としての性質を有するもの、すなわち有体物をいうとされる。その反面、債権その他の無形の財産ないしは利益は没収の対象とならない。よって、賄賂として無形の利益についておよそ没収の対象とならないという本記述前段は正しい。

次に、本記述後段は、必要的追徴について定める197条の5について、金銭換算が可能であれば、その価額は追徴しなければならないとする。この点、同条後段の「没収することができないとき」とは、その賄賂の性質上没収できない場合と没収不能の場合をいい、公務員が自己に代わって債務を弁済してもらったことは、無形の利益であることから性質上没収できない場合に当たる。そして、追徴は、金銭に換算した金額で行うから、金銭に換算可能であれば追徴しなければならないことになる。よって、本記述後段も正しい。

4 正しい

没収の対象は「收受した賄賂」に限られる(197条の5前段)。設問前段のように借金という形をとっても実は金銭の贈与を受ける趣旨であつたのであれば、受領した金銭自体が「收受した賄賂」にあたり、没収の対象となる。よって、本記述前段は正しい。これに対して、設問後段のように本当に借金をしたにすぎない場合、金融上の利益が「賄賂」であり、その金銭自体は197条の5による没収の対象とはならない(なお、その金員は、19条1項3号の「犯罪行為によって……得た物」として同条による任意的没収の対象となり、没収不能のときは19条の2により価額の追徴がなされる(最決昭36.6.22))。よって、本記述後段も正しい。

5 正しい

本記述は、職務上知り得た秘密を漏らすよう請託を受けて賄賂を受受した公務員が秘密を漏らさなかった場合には受託収賄罪が成立し、秘密を漏らした場合には加重収賄罪が成立するとする。この点、受託収賄罪は、公務員がその職務に関し、請託を受けて、賄賂を受受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立する（197 条 1 項後段）。そして、加重収賄罪は、受託収賄罪を犯し、よって職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立する（197 条の 3 第 1 項）。そうすると、秘密を漏らさなかった場合は、職務上不正の行為をしていないので、本記述の公務員には受託収賄罪が成立する。秘密を漏らした場合は、職務上不正の行為をしているから、本記述の公務員には、加重収賄罪が成立する。